

次の【事例】に関する後記アからエまでの各【記述】を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。

【事例】

甲は、某所公園内において、ベンチ上に置いてあるバッグ1個(以下「本件バッグ」という。)を発見し、誰かが置き忘れたものと考え、警察に届け出るため、これを手に取り、同公園から路上に出た。一方、本件バッグをベンチに置き忘れたことに気付いたVは、同公園に戻ろうとして同路上に至ったところ、甲を発見した。Vは、甲が本件バッグを盗んだと疑い、「バッグを返せ。」と言いながら、甲の腹部を2回足で蹴り、甲から本件バッグを奪い、さらに、甲を蹴り上げるような仕草を続けた。甲は、Vの暴行を避けようとして、その胸付近を1回平手で突いたところ、その勢いでVが後方に転倒し、後頭部を路面に打ち付け、失神した。甲は、その頃には、Vが本件バッグの所有者であると分かっていたが、Vの態度に怒りを覚えたことなどから、本件バッグを自己のものにしようと考え、失神しているVからこれを取り上げて自宅に持ち帰った。

その後、甲が本件バッグ内を確認したところ、V名義の預金口座のキャッシュカード等在中の財布、V所有の携帯電話機等の物品が入っていた。甲は、これらを見て、Vの氏名、勤務先のほか、携帯電話機にわいせつな盗撮画像が保存されていることを知り、これを奇貨とし、Vから上記キャッシュカードの暗証番号を開き出して上記口座から預金を引き出そうと思い、勤務先にいたVに電話をかけ、「あんた盗撮してるな。警察に携帯を持って行かれたくないなら、あんたのキャッシュカードの暗証番号を教えろ。」と要求するなどした。Vは、この要求を断れば、盗撮の事実が警察に露見すると思い、やむを得ず甲に同暗証番号を教えた。その後、甲は、上記キャッシュカードを用いて現金自動預払機から現金50万円を引き出した。

【記述】

- ア. 甲が本件バッグを警察に届け出るために某所公園内から持ち出した行為は、Vによる占有の回復を困難にする行為であるため、窃盗罪又は占有離脱物横領罪が成立する。
- イ. Vは本件バッグを甲から取り返す目的で暴行を加えており、この暴行は正当行為に該当するため、甲がVの胸付近を1回平手で突いた行為の違法性が阻却される余地はなく、甲には、暴行罪又は傷害罪が成立する。
- ウ. 甲が本件バッグをVから取り上げた行為は、甲の暴行に起因するVの失神状態に乗じて本件バッグの占有を取得したといえるため、強盗罪が成立する。
- エ. 甲が現金自動預払機から現金50万円を引き出した行為は、甲が、これに先行してVから暗証番号を開き出した時点で、Vの預金の払戻しを受け得る地位を得たことにより、その預金の占有を取得したといえるため、窃盗罪は成立しない。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個

No.439 共通R2-20	犯罪の成否 1	正答率 75%
-------------------	------------	------------

ア 誤っている

甲が本件バッグを警察に届け出るために某所公園内から持ち出した行為は、本件バッグの占有の帰属如何によって窃盗罪（235条）又は占有離脱物横領罪（254条）の客観的構成要件に該当するが、それらの罪が成立するためには、故意のほか不法領得の意思が必要である。判例は、不法領得の意思の内容を、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用もしくは処分する意思としている（大判大4.5.21）。本記述の甲は、本件バッグを警察に届けるためにこれを手に取っており、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用もしくは処分する意思がないため、不法領得の意思が認められない。したがって、甲には、窃盗罪及び占有離脱物横領罪は成立しない。

イ 誤っている

甲の行為は、暴行罪（208条）又は傷害罪（204条）の構成要件に該当する。そこで、正当防衛（36条1項）の成否を検討すると、Vによる暴行は、「急迫不正の侵害」に当たる。なぜなら、①Vは本件バッグを甲から取り返す目的であったが、そもそも甲が本件バッグを手に取った行為には犯罪が成立しない（肢ア）ため、甲との関係で「急迫不正の侵害」に当たらず、Vの暴行につき正当防衛による違法性阻却は認められない、また、②Vは、甲から本件バッグを奪い返した後も、さらに、甲を蹴り上げるような仕草を続けており、甲に対する侵害の継続性が認められるからである。よって、Vの暴行は正当行為ではなく違法であるため、甲の行為には正当防衛が成立し、違法性が阻却される余地がある。

ウ 誤っている

強盗以外の目的で暴行を加えて相手方の反抗を抑圧した後、財物奪取意思を生じ、その反抗抑圧状態を利用して財物を奪った場合、強盗罪（236条1項）が成立するためには、新たな暴行・脅迫が必要である（東京高判昭48.3.26など）。しかし、本記述の甲は、本件バッグを取り上げるにあたって、失神したVに対し、新たな暴行・脅迫を加えていない。したがって、甲の当該行為には窃盗罪が成立するととどまり、強盗罪は成立しない。

エ 誤っている

窃盗罪（235条）の実行行為である「窃取」とは、財物の占有者（事実上の支配者・管理者）の意思に反してその物を自己または第三者の占有下に移すことをいい、ここでの「占有」は、財物に対する事実的支配をいう。本件において、Vの預金（現実の金銭）に対する事実的支配を有するのは銀行であり、暗証番号を開き出したとしても、甲が預金に対して事実的支配を有することにはならない。そして、甲は、暗証番号をVから聞き出すにあたって、Vから盗んだ本件バッグの中にあった携帯電話機の画像をもとにVを脅迫するという犯罪行為を行っているため、甲は、Vの預金の正当な払戻権限を取得したとはいえない。正当な払戻権限のない甲がVの預金を引き出すことは、銀行の意思に反して預金の占有を甲の占有下に移すものであり、「窃取」に当たる。不法領得の意思も問題なく認められる。したがって、甲には窃盗罪が成立する。

以上により、正しい記述は0個であり、したがって、正解は肢1となる。